

1501028-47.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501028-47.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501028-47.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344767/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 22029989 - 01º D.P. AMERICANA, 2126/21/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2344767 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTON DE CASTRO MORAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

CLEYTON DE CASTRO MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque na data e no local descritos na denúncia, mediante grave ameaça e violência física, subtraiu para si coisa alheia móvel, ou seja, um aparelho de telefone celular da marca Poco, avaliado em R\$1.945,00, pertencente à vítima G.G.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 113/114).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 164/168).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 190/191).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 194/198), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Em suas alegações finais, o Doutor Defensor do réu (fls. 202/204), requereu a improcedência da ação, ou a fixação de pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima.

A doutrina distingue duas espécies de roubo: roubo próprio, no qual a violência ou a grave ameaça é exercida antes da subtração da coisa, ou seja, a violência ou grave ameaça é exercida para que o agente subtraia a coisa material e ainda o roubo impróprio, quando o agente emprega a violência contra a pessoa ou a grave ameaça logo após subtraída a coisa.

O roubo próprio se encontra capitulado no "caput" do artigo 157 do Código Penal, e o roubo impróprio se encontra capitulado no parágrafo 1º do mesmo artigo.

Sobre o momento da consumação do delito de roubo, decidiu a 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com voto magistralmente relatado pelo eminente Desembargador Souza Nery, que este se dá no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente consegue retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo, estando portanto já consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo, independentemente do que venha a ocorrer na seqüência, ou seja, do grau de impertubabilidade da posse da res, da existência ou não de perseguição ou de sua intensidade, etc. (Apelação Criminal 990.09.067051-7, j. 13.08.2009).

Nesse sentido, o entendimento do STF:

"... o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato - seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão." (RE nº 102.490-9/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RT 677/428).

A materialidade do delito de roubo se encontra comprovada pelos autos de fls. 07/10, 06 e 11/13, e laudos de fls. 129/130.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por

Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:
"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Em poder do acusado foi encontrado o bem subtraído.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEA, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEA, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175). Erich).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse

de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

Roubo - Objetos subtraídos encontrados em poder do agente - Ônus de demonstrar a legitimidade da posse transferido a defesa - Inteligência do art. 156 do CPP. 131 - Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. RJDTACRIM VOL.6 PÁG. 140 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:- NOGUEIRA FILHO.

Ouvido em juízo, o réu Cleyton confirmou parcialmente a prática do delito, declarando que as partes se encontraram em um bar LGBT, e ofertou para irem a um lugar próximo para manter relações, cobrando pelo programa o valor de trinta reais. Disse, ainda, que após o ato pediu o dinheiro para ir embora, quando a vítima negou pagar, momento em que se agrediram e acabou por pegar o celular para pagamento.

Em audiência, a vítima Gabriel, relatou o ocorrido, declarando que marcou um encontro com umas amigas, e estava as aguardando quando o réu o abordou pedindo dinheiro, informando que não tinha, pois só usava dinheiro. Informou que deu uma "cantada" no réu e este correspondeu, e incentivado pelas amigas, acabou indo com o réu para um lugar próximo, um ginásio abandonado, onde adentraram pulando o muro e mantiveram contato íntimo. Narrou que após o ato uma das amigas ligou, e queria retornar para o bar, mas o réu queria continuar o contato, momento em que o réu ficou bravo e exigiu dinheiro. Declarou que novamente negou ter dinheiro e o réu exigiu o celular, e lhe desferiu um soco para ter acesso ao objeto. Disse, ainda, que tentou argumentar e foi novamente agredido pelo réu, com socos no olho e nariz. E, quando tentou impedi-lo e pediu por socorro, foi agredido e "enforcado" pelo réu. Informou que o réu saiu do lugar, com seu celular, e que a polícia foi acionada por um terceiro. Por fim, disse que os policiais apreenderam o réu, o qual estava na posse do celular. E, negou que o réu tivesse, em algum momento, cobrado pelo relacionamento sexual.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que

segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320). No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354. (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)" (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação"(TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (JTACrim 94/341).

Os Policiais Militares, ouvidos em Juízo, informaram que foram comunicados acerca do roubo, sendo que a testemunha teria acompanhado o indivíduo, e deslocaram-se até o local. Efetuaram a abordagem e, em busca pessoal, localizaram com o réu um celular. Indagado, este confirmou que tinha subtraído o objeto de uma pessoa chamada Gabriel. Disseram, ainda, que entraram contato com a vítima, verificando que encontrava-se bastante machucado no rosto, e esta relatou que havia conhecido o réu naquele dia, e foram para um local mais reservado para manter relações, sendo que após o ato se desentenderam, momento em que o réu passou a exigir dinheiro, e ante a negativa, o réu acabou por exigir o celular e o agredir, para obter o objeto. A vítima reconheceu o celular, o qual foi devolvido. Por fim, as partes foram conduzidas ao hospital, e após a Delegacia.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor

probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu Cleyton, mediante violência e grave ameaça, subtraiu o pertence da vítima.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, tendo em vista a comprovação pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a pretérita condenação do réu pela prática de crimes contra o patrimônio o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

“O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao

juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

Assim, em que pese a defesa apresentada, não é possível a absolvição do réu, ou o reconhecimento da desclassificação do delito.

ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firme e segura de que sofreu grave ameaça, correta a imputação pelo crime de roubo. COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO - REGIME PRISIONAL ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500638-48.2019.8.26.0533; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES E SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - Não cabimento: Bem demonstrada a abordagem efetuada por três indivíduos que, simulando o porte de armas, arrancaram a bolsa do braço da vítima e, portanto, presentes a grave ameaça e violência, impossível falar-se em desclassificação. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007125-34.2009.8.26.0477; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2010; Data de Registro: 09/09/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial. Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu Cleyton, mediante violência e/ou grave ameaça, subtraiu o pertence da vítima.

Desta forma, a condenação do acusado Cleyton é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

O réu Cleyton possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 54/78) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para um delito de roubo (artigo 157, do Código Penal).

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumprir precisa que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pela certidão de fls. 54/78. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Verifica-se a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O dia-multa é fixado no piso.

Regime de cumprimento da pena.

Superada a fixação da pena, com os fundamentos legais já expostos, de rigor a estipulação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, como exigido pelo artigo 59, inciso III do Código Penal.

Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Americana, suas seqüelas para as vítimas, que prestaram depoimento na ausência dos réus, certamente atemorizadas ainda pelos fatos. A própria legislação atual, considerando a violência e a grave ameaça embutida no tipo, veda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Além disso, o réu é reincidente e não provou desenvolver qualquer atividade lícita.

Não é por outro motivo que o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, na maioria de suas Câmaras e distinguindo corretamente as exigências para a fixação da pena e de regime, vinha elegendo o fechado como regra em se tratando de crime de roubo. Nestes autos, volto a anotar, circunstância alguma recomenda fixação de regime mais brando.

Assim o entendimento da doutrina:

"...pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando grande comoção social (MIRABETE, Julio Fabbrini, Execução Penal, 8a ed., Atlas, 1997, p. 255, texto e nota 6)".

"Não se pode porém olvidar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-seá com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, consoante dispõe seu art. 33, § 3º.

Desse modo, num roubo, com emprego de arma, cometido por réu primário, ainda que a pena concreta não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, o juiz poderá determinar o cumprimento da pena em regime fechado. (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", Ed. Oliveira Mendes-APAMAGIS, 1997, p. 8)

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. "É cabível o regime fechado ao condenado reincente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis" (HC 314.296/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1712438/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

ROUBO MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes, de rigor a manutenção do édito condenatório. REGIME PRISIONAL - CRIME GRAVE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e da primariedade do réu. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1530412-93.2018.8.26.0037; Relator: Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Com efeito, não é possível constatar flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se adequado na espécie. [...] 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 326.343/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 25/11/2015)

ROUBO - Regime Prisional Fechado - Necessidade Indeclinável - "É de primeira evidência que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que regem a convivência social. Pelo que, deve o Juiz sujeitar quem o pratica ao mais severo regime prisional. Demais, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, haja vista que subordina a concessão do livramento condicional a exame criminológico elidente, scilicet, atestatório da cessação da potencialidade recidivista" (TACRIM_SP - Ap. nº 1.004.065/3 - São Paulo - 7ª Cam. - Rel. Juiz CORRÊA DE MORAES, j. 13.3.97, v.u.)

REGIME PRISIONAL - Fechado - Substituição pelo regime semiberto - Réu primário - Inadmissibilidade - Determinação do regime inicial que se faz com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal - Hipótese em que o crime de roubo evidencia a periculosidade do agente - Sentença confirmada - Recurso não provido. (Relator: Nelson Fonseca - Apelação Criminal n. 167.440-3 - São Paulo - 15.09.94)

A esse respeito, julgando recurso deste juízo, o Eminentíssimo Magistrado Corrêa de Moraes, com muita propriedade assevera que a fixação de outro regime que não o fechado nos casos de roubo significa não apenas abrir uma porta para a impunidade, mas rasgar a via larga da impunidade, e chega a afirmar que a fixação de outro regime é crime de lesa-sociedade. Cumpre, pela pertinência, transcrever o V. Acórdão, brilhantemente relatado:

"Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e

suficiência (C.P., art. 59).

Esta Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o regime fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais intranquilizadoras expressões da criminalidade, nos tempos correntes.

Vem de molde observar que inexistente relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e a determinação do regime prisional, seguro que esta será feita com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal (cf. § 3º do art. 33).

Sobre o tema, cabe invocar o seguinte ensinamento do STF:

“A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Código Penal, mas, também de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59”(HABEAS-CORPUS nº 70.289 - SP - Primeira Turma p Rel. Min. Sydney Sanches, in RTJ 148/490).

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional (CP, artigo 59, III).

Aliás, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do “condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”, haja vista que subordina a concessão de livramento condicional a exame criminológico elidente, ou, por outras palavras, atestatório da cessação da potencialidade recidivista (CP, parágrafo único do art. 83).

A orientação desta Câmara inspira-se na enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 65.501-SP, verbis;

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias”. (cf. R.T.J. 123/457)

“O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (Habeas Corpus nº 74.301-3, de São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711).

Acresce ponderar que a concessão de regime semi-aberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa..

Anote-se, por último, que, a prevalecer o entendimento pelo qual a determinação do regime prisional é corolário imperativo da quantidade da pena reclusiva aplicada, seria obrigatório, em linha de coerência, aquinhoar o autor de roubo simples com o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”). A impropriedade, inconveniência e injustiça de tal posição saltam aos olhos.

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do código Penal, força é convir que o agente de

roubo sujeita-se ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência "personalidade" marcadamente defeituosa (cf., exemplificativamente, ac. un. na ap. nº 673.255/1 de São Paulo).

Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo"(JUTACRIM 88/870. Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Sem embargo, não falta que, escudado no pretexto da inadequação do sistema carcerário, entenda compatível com o interesse público a manutenção de assaltante em regime aberto, sob a forma domiciliar.

Ora, tangencia a mais cândida ingenuidade supor que perigoso assaltante irá observar escrupulosamente as regras do regime aberto, muito especialmente as relativas ao recolhimento "durante o período noturno e nos dias de folga"...

Conceder regime aberto (e até mesmo o intermediário) a autor de roubo não significa apenas abrir uma porta para a impunidade, mas, em verdade, rasgar a via larga da reincidência. Provam-no as alarmantes estatísticas sobre fugas dos institutos penais agrícolas e sobre a execução de crimes por supostos reclusos em tal sistema. Em poucas palavras: regime outro que não o fechado para assaltante é crime de lesa-sociedade. Regime aberto para rapinante tem o odor, o sabor e a cor de escandalosa impunidade." (os grifos constam do original) (Apelação nº 1.083.043/1, de Americana)

Em julgado, também de recurso contra decisão proferida por este juízo, assim decidiu a 5ª Câmara da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"...o regime inicial fechado para desconto da corporal deve ser mantido, pois a infração penal praticada com emprego de arma e concurso de agentes, revela temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos agentes, a justificar início de regime mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência dos artigos 33, § 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal). (Apelação Criminal nº 00485355.3/1-0000-000, Relator, Desembargador Marcos Zanuzzi, 21 de setembro de 2006).

Ainda, não pode apelar em liberdade, porquanto a gravidade do crime, e o modus operandi devem influenciar na concessão da liberdade para recorrer, e em se tratando de roubo praticado mediante grave ameaça e/ou violência, salvo prova excepcional em contrário, a regra é a prisão provisória do réu.

Assim é o entendimento de jurisprudência, conforme o V. Acórdão que segue, brilhantemente relatado pelo eminente Magistrado Haroldo Pinto da Luz Sobrinho: "O conceito amplo de bons antecedentes, como requisito da liberdade para apelar, compreende, além dos episódios da vida pretérita do réu, as circunstâncias em que praticou o delito tratado na sentença cujo reexame pretende em grau de apelação" (HC - 218.978/1 - TACRIM_SP - 2ª Câmara - Rel. Haroldo Luz - RJDTACRIM 13/196)

E, ainda:

Habeas Corpus - Condenação por roubo majorado - Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência - Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal - Situação fática inalterada - Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a

prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2218120-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Juiz sentenciante, conforme o art. 387, § 1º, do CPP, ao concluir pela necessidade da decretação da custódia cautelar ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito - roubo praticado com arma de fogo e concurso de agentes, em um restaurante - e pelas condições pessoais desfavoráveis do réu, decidiu conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior. Ficou consignado, ainda, que o réu possui condenações penais anteriores por crimes patrimoniais, o que denota sua reiteração delitativa. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 497.109/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

Ademais, o réu encontra-se preso por força de prisão preventiva, e segundo a melhor doutrina, e jurisprudência majoritária, o dispositivo é inaplicável no caso de réu preso provisoriamente.

Segundo o ilustre penalista Damásio Evangelista de Jesus:

"Segundo o entendimento pacífico do STF, essa disposição é inaplicável a réu preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que e/a visa apenas abrandar o princípio da necessidade de e/e recolher-se à prisão para apelar (RHC 54.430, DJU 26.11.76, p. 10203). Assim, réu que por ocasião de sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459, RHC 56.953, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Sobre o assunto, decidiu o TJSP que "Lei n. 5.941, de 1973, é de interpretação restrita. Não nulificou a prisão em flagrante delito, cuja permanência no sistema processual vigente, vai até a sentença. Se esta for absolutória, o réu será posto em liberdade. Se for condenatória, aquela permanência se prolonga, porque um dos seus efeitos (art. 393, I) é ser o condenado conservado na prisão. Se for de pronúncia, só então o magistrado deverá reexaminar a custódia provisória, para revogá-la caso satisfaça o agente os requisitos legais", (RT- 500/318). No mesmo sentido: RT 531/295 e RTJ 88/69; RHC 57.947, DJU 13.6.80, p. 4461, e RHC 58.053, DJU 12.8.80, p. 5786. E, se a acusação apela visando à agravação da reprimenda, o réu permanece detido, ainda que já tenha cumprido o quantum da pena imposta na sentença condenatória (Código de Processo Penal Anotado - Direito Informatizado Saraiva - 1ª Edição em CD-ROM - 1995).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"É que o paciente respondeu o processo preso cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevivendo sentença condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os atributos elencados pelo ilustre impetrante. Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu

preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais favoráveis não são requisitos bastantes para a concessão de liberdade provisória, e, ademais, no caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar ocupação lícita e possuir residência no distrito da culpa. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 207.906/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.02.2012).

E, no caso sub judice persistem os requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois os delitos apurados roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não pode ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade". (AC 2018.0000350330, Habeas Corpus nº 2062136-72.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. França Carvalho, 10 de maio de 2018.)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu CLEYTON DE CASTRO MORAIS à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.
P. I. C.

Americana, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA